

1500774-43.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... forma característica de destino ao narcotráfico; encontraram duas munições intactas; a quantia e variedade de entorpecentes, as formas de acondicionamento, a vultosa quantidade de dinheiro, assim como as demais circunstâncias da prisão demonstram a finalidade de narcotráfico. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls.143/144). A denúncia foi recebida em 26/04/2022 (fls.73/74). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500774-43.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096517/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 24165576 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2096517 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA

Vítima:

A Coletividade e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

02/06/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 02 de junho de 2022, às 16h30, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Dr. Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Rafael Inácio de Oliveira, apresentado para a teleconferência através da Penitenciária de Assis, seu advogado, Dr. Sergio Afonso Mendes OAB/SP 137370, as testemunhas Ronner Antonio de Carvalho, Herculano Lopes Diniz Filho, Matheus Inacio de Oliveira e Aline de Oliveira. Ausente a testemunha Neide Aparecida de Almeida Rodrigues. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao

interrogatório do acusado, a oitiva das testemunhas e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. O advogado do acusado desistiu da oitiva da(s) testemunha(s) Neide Aparecida de Almeida Rodrigues, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Rafael Inácio de Oliveira, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, com a agravante do art. 61, II, "J", do Código Penal. Narrou que no dia 07 de abril de 2022, por volta das 15h02min., na Rua Olímpio de Mello, nº 38, Bloco F-2, apto 01, Parque das Acácias, nesta cidade e Comarca, Rafael trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 123,470g de maconha, e 8,26g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha sob sua guarda 01 munição calibre .22 e 01 munição calibre .380, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurou-se, Rafael mantinha porções de maconha em um depósito de descarte situado a poucos metros da entrada de seu apartamento, além de cocaína no interior de sua residência; o acusado guardava 04 porções grandes de maconha no depósito e 05 porções individualmente embaladas em seu apartamento, para fim de entrega e consumo de terceiros; policiais militares receberam notícias através de populares acerca do comércio de entorpecentes por Rafael no sobredito logradouro e se dirigiram ao local; abordaram-no ao lado do depósito de descartes do prédio e com ele havia uma porção de maconha, dois aparelhos celulares e R\$ 1.026,00 em notas diversas; cães farejadores dos agentes encontraram, no referido depósito de descartes, uma sacola contendo quatro porções de maconha, todas de tamanho semelhantes e embalagens idênticas as que encontradas na posse do acusado; no apartamento acharam mais cinco porções de cocaína, embaladas de forma característica de destino ao narcotráfico; encontraram duas munições intactas; a quantia e variedade de entorpecentes, as formas de acondicionamento, a vultosa quantidade de dinheiro, assim como as demais circunstâncias da prisão demonstram a finalidade de narcotráfico. Notificado, o réu apresentou resposta à acusação (fls.143/144). A denúncia foi recebida em 26/04/2022 (fls.73/74). Nesta data foi feita a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público pleiteou a condenação do réu, sob os argumentos de que: os policiais receberam denúncias de tráfico pelo réu no local, encontraram uma porção de maconha com o réu e outras porções num depósito de lixo, embaladas de maneira praticamente idênticas às que o réu trazia; o irmão do réu disse que as porções de cocaína eram para consumo próprio; as características da porção menor da droga não eram minimamente compatíveis com a droga para uso próprio, não estavam divididas em baseados; o réu tinha dinheiro, não demonstrou origem lícita e é compatível com o tráfico de grande quantia de drogas; não é crível que um trabalhador mantivesse mais de mil reais na carteira; deve a pena ser aumentada pela grande quantia; incide a agravante do crime cometido durante período da pandemia e a agravante da reincidência específica; não é possível aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas; deve ser fixado o regime inicial fechado e não ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e ser decretado o perdimento do bem. A douda Defesa pleiteou a absolvição do réu, sob os argumentos de que: não há prova da condição de traficante, que as porções de maconha que estavam no lixo e as de cocaína que estavam na casa eram do réu; ele trazia apenas uma porção de maconha; o policial não viu o réu mexendo nessa lixeira onde estava os entorpecentes; as porções de maconha estão todas acondicionadas em papel filme transparente; a droga era destinada ao consumo próprio, conforme depoimento da esposa do acusado; é difícil fazer prova do parentesco do síndico com o policial Ronner; a conduta de possuir duas munições, sem ter arma, é atípica e

insignificante; o Ministério Público não fez prova de que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls.12) e laudo de exame químico de entorpecente (fls.20/24). Extraí-se do laudo pericial que foram periciados substância pulverizada e fragmentos vegetais, com resultado positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol (THC), as quais constituem substância de uso proscrito no Brasil. A autoria também é certa e atribuída ao acusado, conforme se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Rafael negou o crime. Afirmou que era sua apenas a porção de maconha que estava no seu bolso, a porção pequena. Relatou que estava abordado no sofá da casa quando foi abordado, estava indo dischavar. Negou estar fora perto da lixeira. Mencionou ter explicado ao policial que nem mora lá e só tinha uma porção. Negou ter visto os policiais achando a droga na lixeira. Frisou que o dinheiro é de seu trabalho como entregador, estava juntando para pagar a moto e outras contas. Narrou que o Ronner é parente do síndico Claudinei, ele lhe xingava de maconheiro e que ia chamar o parente dele policial e se fumesse ia arrumar para minha cabeça. Disse que fazia uns dias que Ronner lhe abordava, cinco meses que lhe parava com caixa de entrega e que ia arrumar para minha cabeça de qualquer jeito. Admitiu que uma das vezes o policial lhe abordou com uma porção de maconha. Declarou que já foi condenado por tráfico de drogas e ganhava cerca de R\$ 2 mil por mês. A testemunha Ronner afirmou que recebeu informações de que Rafael estava traficando no predinho onde ele mora, de populares e moradores que não queriam se identificar. Relatou que foram ao local e ele estava sentado numa mureta com várias portinhas. Mencionou que com ele encontraram dois celulares e R\$ 1026 em notas diversas, cuja origem o réu disse ser de entregas. Declarou que o réu lhes entregou uma porção de maconha e negou ter drogas na residência. Salientou que ele autorizou o ingresso na residência e foi registrado isso em vídeo. Narrou que com a chegada do canil o cão já marcou nessa mureta onde o réu estava, fica no máximo a 10 metros da porta, na frente do apartamento dele. Contou que encontraram porções de maconha prontas para o comércio. Falou que o cão marcou uma caixinha onde havia porções de cocaína, também acharam duas munições calibre 32. Frisou que o réu negou a posse dessa droga e estar traficando. Informou que na Delegacia apareceu uma moça que se identificou como namorada dele, perguntou o que ele estava traficando e o depoente respondeu maconha e cocaína, ela falou "mas ele não trafica cocaína". Negou que o réu tenha fornecido a senha do celular. Esclareceu que a maconha estava no máximo a 5 metros dele, havia 4 ou 5 porções, é um local onde é depositado lixo. Narrou que a cocaína estava numa caixinha, num dos cômodos, com cílios postiços. Disse crer que eram 5 porções de cocaína. Ressaltou que o réu negou a posse de toda droga e assumiu ter achado a munição, a qual estava em outro cômodo, numa caixinha. Explicou que a porção de maconha que estava com o réu era razoável e bem parecida com as outras que foram achadas. Após ver a imagem de fl.15 identificou a porção menor como a que estava com o réu. Afirmou que a denúncia indicava que o réu vendia drogas e recebia via pix. Negou ter registro formal da denúncia. Negou ter visto o réu vendendo drogas. Relatou que o réu estava mexendo no celular quando chegou. Esclareceu que ele estava encostado nessa lixeira onde era recolhido o lixo reciclado. Mencionou que esse predinho tem alambrado, o portão estava aberto, a lixeira fica num canto e há patamar de concreto. Negou conhecer o irmão do síndico chamado Claudinei. Declarou que há vários moradores, mas percebeu que não querem envolvimento e no momento da abordagem só havia o réu. Salientou que o vídeo da autorização foi passado à

polícia. Tais informações foram confirmadas pelo policial Herculano. Relatou ter recebido várias denúncias de que o réu vendia drogas nesse prédio e recebia via pix. Mencionou ter avistado o réu num local usado para guardar lixo e garrafa. Declarou que com o réu havia porção de maconha, dois celulares e dinheiro. Falou que o réu negou vender drogas e autorizou as buscas em filmagem. Acrescentou que no local onde o réu estava o cachorro marcou e lá encontrou sacola com quatro porções

grandes de maconha. Ressaltou que num dos quartos havia cinco porções de cocaína. Disse que o réu era conhecido no meio policial por tráfico. Negou ter outros populares e saber se o síndico estava lá. O informante Matheus afirmou que é irmão do réu. Negou que o réu seja traficante. Falou que as porções de cocaína apreendidas eram suas, o depoente é usuário e acabou entrando nessa vida. Disse que trabalha em dois empregos e ainda tem dívida. Frisou que o réu morava na enfermeira Deolinda com a mãe, é o depoente quem morava no CDHU e frequentava o local quando brigava em casa. Ressaltou que a droga foi achada no quarto do depoente. Salientou que o síndico Claudinei é arrogante e perseguia seu irmão, eles tinham muito desavenças porque o réu ia lá fumar maconha. Informou que o nome do irmão de Claudinei, que é policial, é Ronner. Admitiu ser usuário de maconha e que guarda droga em sua casa. Negou ter 120g, quando compra adquire pouco. Negou saber onde o irmão pegava maconha. Informou que tem venda de drogas no CDHU, não na sua rua. Negou ter visto alguém traficando drogas na frente de casa, mas tem ciganos que convivem e moram na frente de sua casa. Afirmou que o irmão já foi preso por tráfico quando adolescente, mas atualmente não estava fazendo nada. Relatou que o réu trabalhava no mesmo local que o depoente, em turno distinto. A informante Aline afirmou que é esposa do réu. Negou que ele traficasse drogas. Relatou que ele trabalhava como entregador de uma pizzaria e recebia de R\$ 80 a R\$ 100 por dia. Mencionou que sempre brigavam e o réu "se enfiava" na casa do irmão, não gostava disso porque ele era usuário. Declarou o réu ia lá fumar maconha e não sabe se ele cheirava. Salientou que moravam em outra casa com a mãe do réu. Disse ter ido algumas vezes na casa do Matheus buscar o Rafael. Contou que esse dinheiro era do trabalho, o réu não depositava em conta porque devia e tinha que pagar o financiamento da moto. Explicou que o réu guardava o dinheiro consigo mesmo porque devia ao banco. Pois bem. O tráfico de drogas se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. É dizer, as condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal. O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a classificação da conduta em porte para uso próprio (ou tráfico de drogas, a contrário sensu) se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e antecedentes do agente. De acordo com a prova testemunhal produzida, os policiais receberam informações de que Rafael estava traficando no predinho, avistaram ele sentado numa mureta e encostado numa lixeira de coleta de lixo, com ele encontraram uma porção de maconha, dois celulares e R\$ 1026 em notas diversas. Contaram que ele autorizou o ingresso na casa, lá acharam duas munições de arma de fogo e cinco porções de cocaína. Falaram que o cão da polícia marcou o local onde o réu estava encostado e encontraram nesse local de depósito do lixo quatro porções grandes de maconha muito parecidas com a que o réu trazia consigo. Em seu interrogatório o réu negou a venda de drogas, disse que trazia apenas uma porção de maconha para uso próprio, não eram suas as porções que estavam na lixeira e o dinheiro apreendido é fruto de seu trabalho como entregador. O informante Matheus disse que é irmão do réu e Rafael não reside com ele no local. Admitiu ser sua as porções de cocaína, para uso próprio. Tanto ele quanto a informante Aline disseram que o requerido é usuário de maconha. É certo que o réu não foi visto pelos policiais vendendo drogas ou mexendo na lixeira onde acharam as quatro porções de maconha. No entanto, analisando a foto de fl.15 vejo que a porção trazida por Rafael estava embalada com plástico filme idêntico ao das outras quatro porções maiores de maconha, a indicar que eram do mesmo proprietário. Pesa contra o acusado ele estar parado fora do apartamento de seu irmão, encostado numa lixeira onde acharam as outras quatro porções idênticas, e a maconha que ele trazia consigo estar em pedaço e não na forma de baseado, pronto para fumar. Não apresentou nenhuma justificativa plausível para estar parado naquele local, nem para ter o pedaço de maconha no bolso e muito menos para não ter em sua posse algum petrecho

usado por usuários para fumar esse tipo de entorpecente. Além disso, trazia consigo mais de mil reais em dinheiro, em notas diversas, mas não trouxe demonstração da origem lícita deste numerário. É certo que o irmão e a esposa falaram que ele trabalhava como entregador. Mas não trouxe o depoimento de seu empregador, recibos de pagamento de salário ou outra prova idônea a indicar qual era o salário recebido por mês e justificativa plausível para trazer tudo o dinheiro no bolso ao invés de guardar no banco ou em casa. Vale anotar os dizeres dos Professores Vicente Grecco Filho e João Daniel Rassi, "quanto ao perdimento dos bens envolvidos na droga há inversão do ônus da prova, na forma do art. 60, § 2º, da Lei de Tóxicos. Caberá ao acusado demonstrar a origem ilícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes" (Lei de Drogas Anotada, Saraiva, 2007, 2ª tiragem, p.189). Nesse sentido, citem-se os julgados: Inexistindo a prova da origem lícita e havendo presunção de que os bens pretendidos eram produto da prática do tráfico, não há falar em restituição, apresentando-se correta a decretação de perdimento dos bens em favor da União, na forma delimitada pelo art. 60 e § 1º, c/c art. 63 da Lei nº 11.343/06 (TJMG, Apelação Criminal nº 2.0040.08.072861-7/001(1), 4ª Câmara Criminal, Rel. Walter Pinto da Rocha. j. 28.01.2009, unânime, Publ. 11.02.2009, destaquei). Não tendo o réu demonstrado que os telefones celulares e o numerário apreendido não são produto do tráfico, é determinado o perdimento para a União, na forma do artigo 34, da Lei 6.368/76, com redação dada pela Lei 9.804/99, e artigo 48 da Lei 10.409/02. Negado provimento ao apelo defensivo. Parcial provimento ao recurso ministerial. (TJRS, Apelação Crime nº 70021372842, 3ª Câmara Criminal, Rel. Elba Aparecida Nicolli Bastos. j. 10.10.2007, destaquei). Assim, deve ser decretado o perdimento do referido numerário em favor da União, nos termos do art. 91, II, do Código Penal c.c art. 63 da Lei nº 11.343/06. Ainda que se desconsiderem as porções de cocaína que estavam na residência, cuja posse foi assumida por Matheus, é possível concluir que a posse de 5 porções de maconha, quatro delas ocultadas na lixeira, com peso total de mais de 120g, indica claramente a finalidade do narcotráfico. Vale acrescentar que não há indícios de que os policiais tenham forjado ou mentido acerca da localização da droga. Embora o réu tenha apontado um problema envolvendo o síndico do prédio, que seria irmão do policial Ronner, Rafael disse ter sido abordado várias vezes pelo referido policial militar e que apenas uma das vezes ele encontrou uma porção de droga. Ademais, o relato dele foi corroborado pelo policial Herculano, contra quem o réu nada mencionou. Destaco também que o réu é reincidente específico já foi condenado por tráfico de drogas quando maior e menor de idade. Apesar do passado do agente não constituir prova, pode reforçar convicções quando evidencia que o ato incriminado é simples rotina na vida do acusado (RT 564/393). Mesmo tendo o réu dito ser usuário isso não impede que seja também traficante. Mesmo a mais inocente das criaturas sabe que traficantes do final da cadeia delitiva levam consigo, de propósito, uma quantia não muito grande de narcóticos, justamente para fingirem à Polícia que são meros usuários - sujeitos a sanções penais ridículas - e não traficantes, que infernizam a vida não só dos infelizes viciados, mas de todas as pessoas próximas a eles: pais, mães, irmãos, parentes, amigos, etc. Sabe-se que, não raro, usuários de drogas acabam atraídos para o comércio nefasto até como uma forma de subsidiar o vício. Porém, a desclassificação pretendida só é admitida quando se comprova que a posse do entorpecente se destina, exclusivamente, a consumo próprio, situação que não se verifica neste caso concreto. As evidências de que existiram atos ilícitos de posse para mercancia não podem ceder lugar para a posse de drogas para uso próprio. O réu pode até ser usuário de drogas, mas deve prevalecer, para fins penais, no caso em tela, a conduta descrita no tipo que define o crime de tráfico, mais gravosa perante a sociedade, por não ter sido provado que as drogas eram destinadas exclusivamente ao uso próprio. Assim, não é possível desclassificar a conduta para o porte de drogas para o uso próprio. No tocante ao crime de posse de arma de fogo o laudo pericial demonstrou a aptidão das munições. Para a configuração do crime de posse de arma de fogo basta a ocorrência de uma das condutas previstas no artigo 12, da Lei 10.826/03 (possuir ou manter arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Não se exige, para a tipificação, a exposição de outrem a risco. Isso porque se

trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, sendo irrelevante o fato de não ter ocorrido disparo. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta". (AgRg no RHC 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 20.02.2018, DJe 28.02.2018). No entanto, houve a apreensão de apenas duas munições desacompanhadas da arma de fogo. Como bem apontado pelo culto Defensor, tanto a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quanto a do e. Supremo Tribunal Federal tem mudado sua orientação para reconhecer a atipicidade da conduta em situações como esta. Confira-se: AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRADO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, não é admissível a inovação de teses recursais apenas no agrado regimental interpostos contra decisão proferida no recurso especial. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. 1. A decisão da Corte estadual, no sentido de afastar a incidência do princípio da insignificância e anular a sentença absolutória, limitou-se à análise do pedido expressamente formulado pelo Parquet em suas razões recursais. 2. O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso (HC 209.266/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17.03.2016, DJe 31.03.2016). PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. USO RESTRITO. DESACOMPANHADA DO ARMAMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, apesar da posse ilegal de munição configurar crime de mera conduta e de perigo abstrato, nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de projéteis desacompanhados de armamento capaz de deflagrá-los, é cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, haja vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Precedentes. 2. No caso concreto, denunciado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, o agravante foi absolvido sumariamente pelo juízo de primeiro grau, que entendeu sem tipicidade material a conduta de possuir e manter sob a guarda, no interior do imóvel onde reside, apenas 8 (oito) munições de uso restrito, sem a arma de fogo necessária para deflagrá-las. 3. Ao acolher o recurso em sentido estrito do Ministério Público para afastar a incidência do princípio da insignificância e a absolvição sumária, restabelecendo o curso da ação penal, o Tribunal de origem dissentiu do entendimento sedimentado pelos tribunais superiores acerca do tema. 4. Agrado regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de restabelecer a absolvição sumária expedida pelo Juízo de primeiro grau. (AgRg no Recurso Especial nº 1.647.947/SP, 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019). Dessa forma, em atenção ao precedente das Cortes Superiores ressalvo meu entendimento e acolho a absolvição do acusado ante a insignificância da conduta. Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo. Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor do acusado qualquer dirimente: Consoante a inteligência do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena (STF, HC 127241/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado 04-08-2015, STF, RHC 117489/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado 18-06-2013) e constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STF, RHC 122598, Rel. Min. Teori Zavaski,

julgado em 14-10-14). A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevadíssima intensidade pela grande quantidade de droga apreendida (123,47g de maconha). A vultosa quantidade e a variedade do entorpecente apreendido revelam o dolo exacerbado a exigir certo incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, possibilitando a circunstância ao agente atingir maior número de usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias. O réu é reincidente específico, conforme certidão juntada aos autos, o que não interfere nesta etapa da dosimetria. Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. Os motivos e circunstâncias foram inerentes ao tipo. Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que "o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente" (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto a reincidência de Rafael é específica, visto que ele foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e persistiu na senda do mesmo crime. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração da pena maior que a natural em casos como este, pois tal prática "demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminoso". No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 101.918/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 11.05.2010, unânime, DJe 04.06.2010). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. Confira-se: "A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014, destaquei)". Agravo a pena em 1/3 em razão da reincidência específica. Também reconheço a agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus. Reconhecidamente, a sociedade encontra-se vulnerável no âmbito da saúde e, também, no aspecto psicossocial, pois o isolamento e as restrições impostas à circulação de pessoas têm causado conflitos psicológicos que levam, muitas vezes, à utilização de produtos químicos, incluindo entorpecentes. Também há notícias de que policiais tem ficado doentes por causa do Coronavírus, de modo que não é absurdo concluir que essa pandemia pode afetar a fiscalização de crimes como o tráfico. Esta agravante já foi aplicada em no julgamento de um traficante pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do

intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública" (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Somando as duas agravantes majoro a pena no total de ½ (metade) e fixo a pena em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase não há causas de aumento da pena a levar em conta nem é possível aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, visto que se trata de réu reincidente, a indicar que ele se dedica às atividades criminosas e não preenche os requisitos legais. Assim, atinge a pena o montante final de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada no interrogatório, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, da reincidência e do montante da pena. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pelos mesmos motivos. Por fim, a Lei nº 12.736/2012 deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º acrescenta o § 2º ao art. 387 do CPP: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Neste caso concreto o réu não cumpriu 3/5 da pena, de modo que não faz jus à progressão. Assim, apesar da detração ora realizada, o regime inicial de cumprimento da pena restante ainda será o fechado. Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Rafael Inácio de Oliveira, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita; c) DECLARAR a perda, em favor da União, do numerário apreendido nestes autos, com arrimo nos arts. 91, inc. II, do Código Penal, e 63, da Lei nº 11.343/06; d) ABSOLVER o réu Rafael da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 12, caput, da lei 10.826/2003, contra ele formulada na denúncia, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar e é reincidente específico, tudo a indicar periculosidade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e as jurisprudências que adoto como razão de decidir, in verbis: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto

Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013). "(...) Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...)" (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. Em atenção ao pedido feito pelo Ministério Público, extraia-se cópia do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo toxicológico e do termo de depoimento do informante Matheus Inácio de Oliveira e encaminhe-se à Delegacia de Polícia para que seja lavrado termo circunstanciado para apurar a prática, em tese, do crime de posse de drogas para uso próprio. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas. Decorrido o trânsito em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Expeça-se ofício à Autoridade Policial requisitando a incineração dos entorpecentes e autorizando a retirada dos celulares apreendidos pelo proprietário, por si ou representante, no prazo de 30 dias, sob pena de perdimento. Destaque no ofício que diante da nova redação do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria de Justiça, em caso de inércia, fica autorizada a Autoridade Policial a dar destinação aos bens apreendidos, na forma do artigo 123 do CPP; 5) Expeça-se ofício ao Banco do Brasil solicitando que transfira o valor apreendido em favor do FUNAD, constando como CNPJ do favorecido o nº 02.645.310/0001-99, banco 001, agência 1607-1, c/c 170500-8, código identificador nº 2002460000120201, e o envio de comprovante nos autos, no prazo de 10 dias; 6) Comunique-se à SENAD, encaminhando cópia desta decisão e do auto de apreensão; 7) Remetam-se as munições ao Comando do Exército, com autorização para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas (Lei nº 10.826/03, art. 25); 8) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 9) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que: a) retire os celulares apreendidos, no prazo de 30 dias, sob pena de destruição dos aparelhos; b) pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 -

Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es), o(s)rêu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos.1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias.

2. Se não forem apresentadas razões no prazo pela Defesa, intime-se para apresentar no prazo de 24 horas. 3. Se não fizer, intime-se o réu para constituir novo Advogado no prazo de 10 (dez) dias, com a advertência de que se não o fizer será nomeado Advogado Dativo. 4. Decorrido o prazo, nomeie Defensor Dativo junto à OAB e intime-se-o para apresentar as razões recursais no prazo legal. 5. Após a apresentação, abram-se vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 6. Extraia-se a guia de execução provisória e encaminhe-se à VEC competente; 7. Por fim, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta, anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 01 de junho de 2038. Saem os presentes intimados". Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Eu, Antônio Celso Sanches, digitei.